

1500303-85.2022.8.26.0545

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Laércio José Mendes Ferreira Filho

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/09/2022

... informados da ocorrência da prática do tráfico de drogas na ocasião, se pode fazê-lo qualquer do povo " (RHC nº 20.714, rel. Min. Hamilton Carvalhido).

Nesta esteira também o posicionamento do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Apelação. Tráfico de drogas. Sentença condenatória (artigo 33,"caput", da Lei nº 11.343/06). Recurso da defesa. PRELIMINAR. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

2ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12903-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500303-85.2022.8.26.0545

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2069510/2022 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 23567983 -

DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 2069510 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX SANDRO MARTINS NERIS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Laércio José Mendes Ferreira Filho

Vistos.

ALEX SANDRO MARTINS NERI foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, da Lei 11.343/2006, porque no dia 13 de março de 2022, na Rodovia Benevenuto Moreto, 1 - KM 1 - Caetanópolis, nesta cidade e Comarca, trazia consigo, com a finalidade de

comércio, três porções de maconha, pesando aproximadamente 65,5 gramas, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Devidamente notificado, o acusado apresentou defesa preliminar às fls. 121/123. Recebida a denúncia aos 24 de maio de 2022 (fl. 130), deu-se a regular instrução do processo.

Durante a instrução processual ouviram-se duas testemunhas de acusação e, ao final, promoveu-se o interrogatório do acusado (fl. 166).

Em seguida as partes apresentaram alegações finais.

A acusação requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia, certa de que as provas dos autos estão em sintonia e autorizam a condenação (fl.166).

A defesa postulou, preliminarmente, a nulidade ab initio do procedimento, embasada na ilicitude da abordagem realizada pelos guardas municipais. No mérito, pugnou pela desclassificação para o crime previsto no artigo 28, da lei de drogas (fl.166).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente não assiste razão a defesa quanto à questão cogitada em preliminar. Diferentemente do acenado, descabido falar-se, na espécie, em prova ilícita, mercê da conduta dos guardas municipais. Isto porque não se vislumbrou durante a execução da prisão ação que ultrapassasse as raízes das funções que os agentes municipais estão autorizados a exercer.

Embora o texto da Constituição Federal que prevê a possibilidade da constituição da guarda municipal explicita que sua função consiste na proteção dos bens, serviços e instalações do Município (artigo 144, parágrafo 8º), isto não significa que seus integrantes não ostentem a condição de agentes da autoridade, até porque o dispositivo acha-se inserido e há que se atentar para a interpretação sistemática, que sobreleva a puramente gramatical no capítulo da segurança pública.

Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça que os guardas municipais estão " legitimados, dentro do princípio da autodefesa da sociedade, a fazer cessar eventual prática criminosa, prendendo quem se encontra em flagrante delito, como de resto facultado a qualquer do povo pela norma do art. 301, do Código de Processo Penal ". E " se a lei autoriza a prisão em flagrante, evidentemente que faculta também a apreensão de coisas, objeto do crime " (RHC nº 7.916, rel. Min. Fernando Gonçalves).

No mesmo sentido, " não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante e, conseqüentemente, em prova ilícita, porque efetuada por guardas municipais, que estavam de ronda e foram informados da ocorrência da prática do tráfico de drogas na ocasião, se pode fazê-lo qualquer do povo " (RHC nº 20.714, rel. Min. Hamilton Carvalhido).

Nesta esteira também o posicionamento do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Apelação. Tráfico de drogas. Sentença condenatória (artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06). Recurso da defesa. PRELIMINAR. Alegação de nulidade em razão da prisão e apreensão das drogas ter sido feita por guardas municipais. Inconsistência. Não se afigura ilícita a prisão em flagrante e a apreensão das drogas realizada por guardas municipais. Decisões do Superior Tribunal de Justiça nesta linha.

Preliminar rejeitada. MÉRITO. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do réu. Materialidade e autoria comprovadas. 2.

Inaplicabilidade da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06. Réu reincidente. 3. O grau de culpabilidade da conduta e a reincidência justificam o regime inicial fechado para a pena privativa de liberdade e obstam a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, além da própria quantidade da sanção. 4. Penas inalteradas. Recurso improvido. (TJ-SP -

APL: 00228073920148260320 SP 0022807-39.2014.8.26.0320, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 14/06/2016, 2ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 15/06/2016)

Apelações. Crime de tráfico de drogas. Condenação dos réus como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Recursos da defesa. PRELIMINAR. Ação dos guardas municipais que guardou juridicidade. Situação de flagrante delito que justificava a prisão dos réus. Não se afigura ilícita a prisão em flagrante e a apreensão das drogas realizada por guardas municipais. Decisões do Superior Tribunal de Justiça nesta linha. Preliminar rejeitada. MÉRITO. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal dos réus. Materialidade e autoria comprovadas. 2. Penas inalteradas. Apelos improvidos. (TJ-SP - APL: 00137352120158260602 SP 0013735-21.2015.8.26.0602, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 16/03/2017, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/03/2017)

APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Absolvição com fulcro no inciso VI, do art. 386, do CPP - Prisão em flagrante efetuada por guardas municipais - Provas ilícitas - Inocorrência - Precedente STF e TJSP - Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Condenação que se impõe - Causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas devida no patamar mínimo - Imposição de regime inicial fechado - Recurso provido, portanto. (TJ-SP - APL: 00014730920168260536 SP 0001473-09.2016.8.26.0536, Relator: Ricardo Sale Júnior, Data de Julgamento: 25/10/2018, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/10/2018)

HABEAS CORPUS - Tráfico de Entorpecentes - Prisão em Flagrante realizada pela Guarda Municipal - Ilícitude dos elementos indiciários colhidos na fase inquisitiva - Prova Ilícita - Falta de Justa Causal - Trancamento da Ação Penal - Não Verificado - Art. 301 do CPP - Ordem denegada. 1. A prisão em flagrante efetuada por guardas municipais, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (art. 144, § 8º, da CF), constitui ato legal, em proteção à segurança social. 2. Se a qualquer do povo é permitido prender quem quer que esteja em flagrante delito, não há falar em proibição à Guarda Municipal de proceder à prisão - art. 301 do CPP. 3. Na hipótese há indícios de autoria e materialidade idôneos, não havendo justa causa para o trancamento da ação penal. 4. Ordem denegada. (TJ-SP - HC: 22283055420158260000 SP 2228305-54.2015.8.26.0000, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 25/11/2015, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/12/2015)

No mérito, a materialidade do delito contra a saúde pública está plenamente comprovada.

O laudo de exame químico toxicológico (fls. 102/104) descreveu e concluiu que a substância analisada é maconha, caracterizadas por meio de análises químicas e cromatográficas.

A autoria igualmente é certa.

O acusado em seu interrogatório admitiu a propriedade da droga apreendida, argumentando que a destinaria ao seu consumo pessoal.

Alex esclareceu que tão logo comprou a droga de uma pessoa que estava na via pública, foi surpreendido por guardas municipais.

Por outro lado, os guardas que apreenderam a droga relataram que na ocasião dos fatos realizavam patrulhamento de rotina quando visualizaram o acusado no interior de um veículo entregando algo para um rapaz que estava na rua. Contaram que quando ele notou a presença da viatura, empreendeu fuga. Diante disso, perseguiram-no por aproximadamente três quilômetros e o abordaram.

Realizada revista, localizaram no interior do porta-luvas do veículo três porções de maconha, além de uma quantia em dinheiro.

Pois bem, este é o quadro probatório dos autos.

Certo da autoria e da materialidade de crime contra a saúde pública, não ficou absoluta, latente o suficiente para ensejar a condenação, a prova a respeito do tráfico imputado. Senão vejamos.

O Guarda Municipal Carlos relatou que somente abordou o acusado porque o viu entregando um embrulho para uma pessoa que estava na via pública. Salientou que Alex se encontrava na condução de um veículo e, quando visualizou os guardas municipais, saiu rapidamente do local com o carro.

Acrescentou que o acusado foi perseguido por diversas ruas até ser abordado.

Disse, ainda, que aquela pessoa que estava na via pública, que teria recebido um

embrulho do acusado, não fora abordada durante a diligência realizada pela Guarda Municipal. Informou, também, que os guardas municipais que a realizaram estavam em três motos. Por fim, declarou que não conhecia o acusado de outras abordagens. Eis suas palavras:

D.: Nós estávamos juntamente com a Polícia Militar em saturação pelo bairro com intuito de combater ilícito. Quando nós estávamos com a motocicleta em local conhecido como ponto de venda de droga visualizamos um veículo entregando algo volumoso pra um rapaz que tava na rua. Isso nos chamou a atenção, fomos no encalço do veículo, o mesmo empreendeu fuga por proximamente uns 3 km. Aí ele, a gente conseguiu abordar. Com ele nada de ilícito foi encontrado, porém no porta-luvas tinha uma, uma bolsa. E nessa bolsa tinha 350 e poucos reais e 3 porções grande de, de maconha. Indagado em entrevista informal o mesmo falou que estaria vendendo pra pagar uma dívida.

J.: Esse rapaz que o senhor disse que ele teria feito contato quando os senhores o visualizaram, os senhores não abordaram esse rapaz?

D.: A gente não conseguiu, a gente priorizou o veículo porque as motos vai na frente, aí a gente pensou que as viaturas ia conseguir abordar, mas abordaram outros indivíduos menos ele.

J.: Sei e esse contato que ele fez com esse rapaz o senhor viu se ele tava pegando alguma coisa, entregando, deu pra saber?

D.: Entregando, foi nítido.

J.: Normalmente os senhores abordam quem tá a pé, né, não quem tá de carro?

D.: Isso, isso que chamou atenção porque o que tava no carro tava entregando, por isso que a gente resolveu abordar o do veículo.

No mesmo sentido foram as palavras do GM Sandro. Ele disse que observou o momento em que o acusado, que estava dentro de um veículo, entregou alguma coisa para um rapaz, que se encontrava a pé na via pública. Mencionou, ainda, que no momento que presenciou esse fato, estava a uma distância de 100 a 200 metros dos envolvidos, motivo pelo qual não foi possível constatar o que o acusado, de fato, teria entregado àquela pessoa, tampouco o tamanho do embrulho.

Neste particular, denota-se evidente contradição entre a versão trazida pelos guardas municipais. Isso porque, o GM Carlos descreveu que a conduta do acusado foi visualizada a poucos metros, cerca de 20 a 25 metros, além de mencionar que se tratava de um "pacote volumoso".

Se não bastasse, os guardas deixaram de abordar a pessoa que estava a pé, na via pública, para perseguir o acusado, que diga-se, se encontrava na condução de um veículo.

Ora, os guardas municipais patrulhavam em três motos, conforme informação apresentada pelo GM Carlos, o que nos indica que facilmente poderiam os agentes públicos se dividirem e promoverem a abordagem de ambos. Mas, ao contrário, limitaram-se a perseguir o veículo conduzido pelo acusado e deixaram de abordar a pessoa que, numa eventual fuga, certamente seria capturado rapidamente, já que fugiu "correndo".

Pontue-se, que os guardas disseram que perseguiram o acusado por diversas ruas, por aproximadamente três quilômetros. Portanto, se de fato a droga apreendida em poder dele estivesse destinada ao tráfico de drogas, certamente durante a perseguição por vários quilômetros, na esteira do narrado pelos agentes públicos, teria tentado de alguma maneira se desfazer do entorpecente.

Ademais, o rotineiro é que os traficantes fiquem em determinados pontos da via, aguardando que possíveis usuários se desloquem até ele, muitos utilizando-se de veículos. Imaginar que o traficante fique circulando com seu veículo pelas ruas e, ao se deparar com um usuário caminhando na via pública, pare seu veículo e realize a venda aquele transeunte é uma verdadeira afronta ao raciocínio lógico deste Juízo.

Em que pese a existência de diversas contradições em seus depoimentos, não se trata, aqui, de lançar um véu de suspeição sobre as palavras dos agentes públicos que, durante patrulhamento de rotina, depararam-se com o acusado e localizaram a droga.

Isto está comprovado nos autos.

O que não está demonstrado, com a certeza necessária para a fundamentação de um édito condenatório, é a destinação que seria dada ao entorpecente.

De forma que eventual condenação do acusado pelo hediondo crime de tráfico ilícito de entorpecentes teria como fundamento apenas e tão-somente a apreensão da droga.

O que não se admite, obviamente.

Lado outro, a quantidade da droga, na espécie, não é capaz de apontar a traficância, uma vez que é possível a utilização com facilidade do material apreendido (65 gramas de maconha).

Saliente-se, que a defesa colacionou aos autos comprovação de que o acusado exercia atividade lícita e que o dinheiro com ele apreendido era fruto de seu trabalho (fls. 124/125).

Assim, não há nenhuma prova ou elemento que indique que o acusado estaria guardando com ele a droga para comercialização ou entrega a terceiros. Na dúvida entre a guarda para uso próprio ou tráfico, deve se aceitar a versão do acusado.

Logo, levando em conta as versões apresentadas nos autos, tudo leva a crer que foi surpreendido logo após ter adquirido o entorpecente com o traficante que não foi abordado pelos guardas municipais.

As vãs tentativas de caracterizar a conduta do acusado como tráfico, quando há menção de que ele teria confessado informalmente aos guardas municipais de que a droga com ele apreendida estaria destinada ao comércio ilícito são genéricas demais para sustentar uma incriminação e não ostentam segurança para que o Juízo forme uma convicção segura.

A finalidade de traficar deve estar bem evidenciada, cristalina. A quantidade da droga, o local e a forma como foi encontrada, tudo indica para uma posse com a finalidade de uso próprio.

Diante deste contexto, incumbindo ao Ministério Público provar de maneira absoluta a traficância, o que não ocorreu, a desclassificação é medida que se impõe.

Os fatos descritos na denúncia implicitamente abordam a conduta de possuir substância entorpecente que causa dependência física ou psíquica, com a finalidade de uso próprio. O que existe nos autos é a autoria e a materialidade deste delito.

Sobre o tema:

TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. Recurso ministerial visando à condenação do apelado pelo delito de tráfico - IMPOSSIBILIDADE. Ausência de provas seguras de traficância. Restou provado nos autos que o dinheiro apreendido era produto de empréstimo. Policiais que confirmaram ser o apelado usuário de entorpecentes. Decisão de desclassificação mantida - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 36908420098260531 SP 0003690-84.2009.8.26.0531, Relator: Ruy Alberto Leme Cavaleiro, Data de Julgamento: 27/11/2012, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/11/2012).

PENAL. APELAÇÃO. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. Apelo da Acusação para condenar o réu por tráfico de drogas, sem a concessão do redutor legal e com imposição do regime inicial fechado. Descabimento. Adequação do acervo de provas à desclassificação. A decisão de desclassificação do crime de tráfico para o de uso de drogas mostrou-se apropriada, diante da não uniformidade dos depoimentos dos policiais que o autuaram, bem como por estar na posse de pouca quantidade de droga, o que por si só não justificaria o "tráfico", e por se encontrar caminhando, quando abordada, em local que não se destinava ao hediondo comércio. Negado provimento. (TJ-SP - APL: 00010673220148260447 SP 0001067-32.2014.8.26.0447, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 25/05/2017, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/05/2017).

Tráfico de drogas - Confissão a propósito da posse para uso próprio - Apreensão de porções de cocaína em número compatível com o consumo - Prova oral pouco esclarecedora a propósito do tráfico - Acusado surpreendido em frente à sua casa - Dúvida razoável - Desclassificação para o art. 28, da Lei de Tóxicos - Cabimento - Recurso provido. (TJ-SP - APL: 00011358720158260530 SP 0001135-87.2015.8.26.0530, Relator: Alexandre Almeida, Data de Julgamento: 07/11/2018, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/11/2018).

Concluída a motivação, à dosagem da pena devem ser atendidas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal.

Em fundamentação à aplicação da pena saliento que a reprovabilidade da conduta praticada pelo condenado não justifica aumento na pena base.

Seus antecedentes recomendam exacerbação, conforme indica a certidão de fl. 55. Os autos não fornecem elementos seguros para análise da conduta social e da personalidade do agente.

Os motivos, circunstâncias e consequências do crime não justificam maior reprovação, razão pela qual as penas serão fixadas em seu mínimo legal.

Na segunda fase, certificada a reincidência do condenado à fl. 56, observo que ela concorre com a atenuante da confissão, razão pela qual elas serão compensadas.

Causas gerais ou especiais de aumento ou diminuição não foram detectadas.

Em virtude das circunstâncias em que ocorreram os fatos, o Juízo entende ser insuficiente para o caso a aplicação de advertência, motivo pelo qual outra será a sanção imposta, a teor do artigo 28, de referida legislação.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de CONDENAR ALEX SANDRO MARTINS NERIS, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 28, "caput", da Lei 11.343/2006, à pena de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRATUITOS À COMUNIDADE, pelo prazo de 05 meses, na forma dos §§ 3º a 5º, do artigo 28, da Lei 11.343/2006, a ser cumprida a medida na forma a ser designada pelo Juízo da execução.

A aplicação da detração da pena restritiva de direito pelo período de custódia preventiva será melhor apreciada pelo Juízo da Execução, uma vez que não compete ao Juízo de cognição a questão, por se tratar de matéria restrita aquele órgão.

Facultado o recurso em liberdade haja vista que o sentenciado se encontra nesta condição e não se avistam como presentes os requisitos da prisão cautelar.

Com o trânsito em julgado, defiro a restituição do dinheiro e do aparelho celular apreendidos em poder do sentenciado. Na mesma esteira, para a devolução do veículo, deverá a defesa apresentar documento que comprove a propriedade em favor do sentenciado ou de terceira pessoa (petição de fls.175/179).

Após o trânsito em julgado, promovam-se as comunicações de praxe e providencie-se o necessário ao cumprimento da pena.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. Intime-se.

Bragança Paulista, 01 de setembro de 2022.

LAÉRCIO JOSÉ MENDES FERREIRA FILHO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA